

1503905-48.2021.8.26.0536

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Denise Gomes Bezerra Mota

Comarca: Guarujá

Foro: Foro de Guarujá

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 10/04/2022

... CONSTITUCIONAL, PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. APLICAÇÃO DA LEI N. 8.072/90 AO TRÁFICO DE ENTORPECENTES PRIVILEGIADO: INVIABILIDADE. HEDIONDEZ NÃO CARACTERIZADA. ORDEM CONCEDIDA. 1. O tráfico de entorpecentes privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei n. 11.313/2006) não se harmoniza com a hediondez do tráfico de entorpecentes definido no ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Guarujá

Foro de Guarujá

1ª Vara Criminal

Rua Silvio Daige, 280, Guarujá-SP - cep 11440-550

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1503905-48.2021.8.26.0536 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1503905-48.2021.8.26.0536

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2322705/2021 - DEL.POL.GUARUJA, 21634223 - DEL.POL.GUARUJA, 5788/21/203 - DEL.POL.GUARUJA, 2322705 - DEL.POL.GUARUJA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MARCOS PEREIRA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Denise Gomes Bezerra Mota

Vistos.

Marcos Pereira, qualificado nos autos, está sendo processado como incurso no crime do artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/2006, porque, no dia 26 de novembro de 2021, por volta das 19:00 horas, na Rua Duque de Caxias, nº 125, Sítio Conceiçãozinha, nesta cidade e comarca de Guarujá, trazia consigo, para fins de entrega a consumo de terceiros, 40 (quarenta) gramas de "crack", 360 (trezentos e sessenta) gramas de cocaína e 755 (setecentos e cinquenta e cinco) gramas de maconha, substâncias ilícitas que determinam dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, consoante o auto de constatação preliminar de fls. 08.

O réu foi notificado (fls. 110) e apresentou defesa prévia (fls. 116/118), que não comportou acolhimento, e a denúncia foi recebida (fls. 124/126).

Foi juntado aos autos o laudo de exame químico-toxicológico realizado nas drogas apreendidas (fls. 139/141).

Durante a instrução criminal, foram ouvidas duas testemunhas comuns e o réu foi interrogado (fls. 160/161). A instrução foi declarada encerrada e pelas partes não foram requeridas diligências, nos termos do artigo 402 do Código de Processo Penal (fls. 158).

O representante do Ministério Público, nos memoriais, requereu a procedência da ação nos exatos termos da denúncia, argumentando que a autoria e a materialidade restaram provadas durante a instrução criminal (fls. 164/171).

Nos memoriais, a defesa requereu a improcedência da ação com a absolvição do réu, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Subsidiariamente, em caso de entendimento diverso, requereu a fixação da pena-base no mínimo legal, o reconhecimento e a aplicação da atenuante da confissão espontânea, a aplicação da causa de diminuição da pena prevista no artigo 33, parágrafo 4º da Lei nº 11.343/06, a fixação do regime inicial aberto, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, bem como a concessão ao réu do direito de apelar em liberdade (fls. 179/185).

É o relatório.

Decido.

A ação é procedente.

Com efeito, a materialidade do delito está demonstrada pelo auto de constatação preliminar de fls. 8, pelo auto de exibição e apreensão de fls. 11/12, pelas fotografias de fls. 18/22, 30/34, pelo laudo pericial de fls. 136/138, pelo laudo de exame químico-toxicológico de fls. 139/141, bem como pela prova oral coligida nos autos.

A autoria do réu também restou incontroversa pelas provas produzidas durante a instrução criminal.

Interrogado na fase policial, o réu negou a prática delitiva. Alegou ser usuário de cocaína. Na data dos fatos, encontrava-se em via pública quando foi abordado por policiais militares que encontraram em seu bolso 1 (um) pino de cocaína para uso próprio. Afirmou para os policiais que não era traficante. Foi levado pelos policiais a uma casa desconhecida, onde foram realizadas buscas e encontradas diversas drogas. Desconhece quem seja o proprietário da casa e das drogas encontradas pelos policiais militares (fls. 10).

Em seu interrogatório judicial, o réu alterou sua versão sobre os fatos, e confessou a prática delitiva. Relatou que um indivíduo ofereceu-lhe R\$ 200,00 para que levasse as sacolas contendo drogas a outra pessoa. O interrogando aceitou a proposta e dirigiu-se ao destino informado para a entrega das sacolas, mas no caminho foi abordado por policiais militares, o que resultou em sua prisão em flagrante e na apreensão das drogas. Ressaltou o acusado que aceitou a proposta financeira do desconhecido porque está desempregado e passando por dificuldades. Trabalhava como ajudante de pedreiro, mas em razão da situação de pandemia não tem conseguido serviço. Encontra-se arrependido, pois não é desse meio e nunca havia praticado essa conduta (fls. 160/161).

E a confissão judicial do réu, como seria de rigor, restou confirmada pelas provas produzidas nos autos, que demonstraram o inequívoco envolvimento do acusado no tráfico de drogas e não foi apresentada situação capaz de excluir o crime ou isentá-lo de pena.

Senão vejamos.

O policial militar Renno César Garcia da Silva, no seu depoimento judicial, relatou que na data dos fatos participava de uma operação policial no Sítio Conceiçãozinha e fazia incursão a pé em um beco sem denominação, acompanhado do policial Azevedo. Em dado momento, ao chegarem ao cruzamento desse beco com a Rua Duque de Caxias, visualizou o acusado com uma mochila de cor preta na mão, e, sem motivo aparente, o acusado, ao perceber a presença dos policiais, deu meia volta e começou a andar em passos rápidos. A equipe foi em seu encalço e o deteve poucos metros adiante. O réu foi submetido a revista pessoal e nada de ilícito foi encontrado junto a seu corpo. A mochila que o acusado portava foi aberta no local, na presença dos que se encontravam presentes - moradores e policiais - e no interior dela havia uma quantidade significativa de maconha, cocaína e crack. Indagado a respeito, o acusado permaneceu em silêncio. O depoente não conhecia o acusado (fls. 160/161).

Wellington Mercês de Azevedo, policial militar, em Juízo, relatou que na data dos fatos participava de uma operação policial no Sítio Conceiçãozinha, e fazia incursão a pé acompanhado do policial Renno César, em um beco sem denominação. Em dado momento, ao chegarem ao cruzamento desse beco com a Rua Duque de Caxias, avistaram o acusado com uma mochila de cor preta na mão, e, sem motivo aparente, o acusado, ao perceber a presença dos policiais, deu meia volta e começou a correr. A equipe conseguiu detê-lo poucos metros adiante. O réu foi submetido a revista pessoal e nada de ilícito foi encontrado junto a seu corpo. No entanto, a mochila que o acusado portava foi aberta no local e no interior havia maconha, cocaína e crack. Indagado a respeito das drogas, o acusado exerceu seu direito ao silêncio. O depoente não conhecia o acusado (fls. 160/161).

Ressalte-se que os depoimentos dos policiais merecem total credibilidade, pois não se pode presumir a intenção de incriminar falsamente o acusado da prática de delito, ainda mais quando seus depoimentos são seguros, precisos e uniformes desde a fase inquisitorial. Ademais, não restou comprovada qualquer razão concreta de suspeição.

A propósito, vem decidindo o Colendo Superior Tribunal de Justiça que:

"[...] O depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova [...]" (STJ, HC 471082 / SP, Rel. Ministro Felix Fischer, j. 23/10/2018, DJe. 30/10/2018).

"[...] Os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, [...]" (STJ, HC 496335 / SP, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, j. 02/04/2019, DJe 08/04/2019).

Tem-se que diante do contexto em que ocorreram os fatos, do teor dos depoimentos dos policiais, que narraram de forma segura e harmônica a conduta do acusado, diante da quantidade e da variedade dos entorpecentes apreendidos, bem como da forma de acondicionamento dos entorpecentes, e de todas as circunstâncias que culminaram com a abordagem e a prisão do réu, restou comprovada a conduta típica narrada na inicial acusatória. Ainda, o réu confessou os fatos narrados na denúncia.

Portanto, diante das provas produzidas, a autoria do delito é indiscutível. É certo que o acusado trazia consigo os entorpecentes, e os entorpecentes eram destinados para a entrega a consumo de terceiros, ante a conduta do réu narrada pelos policiais, destacando-se que o artigo 33 da Lei nº 11.343/06 descreve condutas variadas, podendo ficar configurado o delito de tráfico de drogas ainda que o agente não tenha sido surpreendido praticando atos de comércio, como no presente caso.

Por fim, o crime de tráfico imputado ao réu restou consumado, uma vez evidenciado que os entorpecentes apreendidos com o réu eram destinados à entrega para consumo de terceiros.

Definida a conduta do réu, passo à dosimetria da pena.

Na primeira fase, considerando os critérios do artigo 59 do Código Penal e do artigo 42 da Lei nº 11.343/2006, entendo que o comportamento do réu se revestiu de reprovabilidade excepcional, dada a considerável quantidade e a natureza dos entorpecentes apreendidos - 26,2 gramas de "crack", 167,5 gramas de cocaína e 621,7 gramas de maconha, conforme fls.139/141 - motivo pelo qual elevo a pena-base em 1/6, perfazendo o montante de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Na segunda fase, reconheço e aplico a circunstância atenuante da confissão espontânea, prevista no artigo 65, inciso III, alínea "d", reduzindo a pena em 1/6, o que perfaz 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa. Destaco que a atenuante não pode levar a pena abaixo do mínimo legal,

Na terceira fase, em relação à aplicação do redutor previsto no artigo 33, parágrafo 4º, da Lei nº 11.343/2006, verifico que o acusado preenche os requisitos legais, pois é primário, sem antecedentes, e inexistem indícios de que integre

organização criminosa. As circunstâncias dos fatos demonstraram que o réu agiu de forma ocasional. Tem-se que a intenção do legislador, ao permitir a redução das sanções penais, foi diferenciar o traficante contumaz, que dispõe de sofisticado aparato organizado, daquele eventual. No caso dos autos, não obstante o réu trazer consigo considerável quantidade e variedade de drogas, sendo algumas com alto poder viciante, pelas peculiaridades do caso concreto, entendo que se trata de acusado que agiu de forma ocasional, o que não impede a aplicação do redutor. Com efeito, as circunstâncias dos fatos demonstraram que o réu trazia consigo os entorpecentes para a entrega a consumo de terceiros. No entanto, há de se ressaltar que acusado conta com 38 anos de idade, apresenta a condição de primário e não possui antecedentes, o que evidencia não se tratar de indivíduo que faz da atividade criminosa um meio de vida. Sendo assim, na terceira fase da dosimetria penal aplico o redutor previsto no artigo 33, parágrafo 4º, da Lei nº 11.343/06, reduzindo a reprimenda em 2/3, o que perfaz o montante de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa.

Torno definitiva a pena aplicada.

Fixo o valor do dia multa em seu patamar mínimo, nos termos do artigo 49, parágrafo 1º, do Código Penal, sendo que o valor do dia multa deverá ser objeto de correção monetária, na forma do artigo 49, parágrafo 2º, do Código Penal.

Em relação ao regime prisional, considerando que o pleno do STF decidiu recentemente que "O chamado tráfico privilegiado, previsto no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 (Lei de Drogas) não deve ser considerado crime de natureza hedionda." (HC 118533, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 23/06/2016), que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao julgar o HC nº 111.840/ES, afastou a obrigatoriedade do regime inicial fechado para os condenados por crimes hediondos e equiparados, devendo-se observar, para a fixação do regime inicial de cumprimento da pena, o disposto no artigo 33, c.c. o artigo 59, ambos do Código Penal, modifico entendimento anterior e passo a entender que o crime de tráfico de drogas privilegiado não é crime equiparado a hediondo, de forma que o regime será fixado de acordo com o disposto nos artigos 33 e 59 do Código Penal.

Neste sentido, a jurisprudência:

"HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL, PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. APLICAÇÃO DA LEI N. 8.072/90 AO TRÁFICO DE ENTORPECENTES PRIVILEGIADO:

INVIABILIDADE. HEDIONDEZ NÃO CARACTERIZADA. ORDEM CONCEDIDA. 1. O tráfico de entorpecentes privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei n. 11.313/2006) não se harmoniza com a hediondez do tráfico de entorpecentes definido no caput e § 1º do art. 33 da Lei de Tóxicos. 2. O tratamento penal dirigido ao delito cometido sob o manto do privilégio apresenta contornos mais benignos, menos gravosos, notadamente porque são relevados o envolvimento ocasional do agente com o delito, a não reincidência, a ausência de maus antecedentes e a inexistência de vínculo com organização criminosa. 3. Há evidente constrangimento ilegal ao se estipular ao tráfico de entorpecentes privilegiado os rigores da Lei n. 8.072/90. 4. Ordem concedida" (Pleno, HC nº 118.533, rel. Min. Cármen Lúcia, j. 23/06/2016 grifos da reprodução).

"HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ART. 33 DA LEI 11.343/2006. AFASTAMENTO DO REDUTOR PREVISTO NO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. ACUSADO SEM OCUPAÇÃO LÍCITA. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. RESTABELECIMENTO DA FRAÇÃO REDUTORA ESTABELECIDNA SENTENÇA. REGIME PRISIONAL FECHADO COM BASE NA HEDIONDEZ E NA GRAVIDADE ABSTRATA DO DELITO. IMPOSSIBILIDADE. REGIME ABERTO DEFERIDO, POIS PRESENTES OS REQUISITOS LEGAIS. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. - O Superior Tribunal de Justiça, seguindo o entendimento firmado pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, não tem admitido a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso próprio, prestigiando o sistema recursal ao tempo que preserva a importância e a utilidade do habeas corpus, visto permitir a concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade. - Para aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, o condenado deve preencher cumulativamente todos os requisitos legais, quais sejam, ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas nem integrar organização criminosa, podendo a reprimenda ser reduzida de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços),

a depender das circunstâncias do caso concreto. - Não há como manter a fundamentação utilizada pelo Tribunal de origem, que afastou a figura do tráfico privilegiado sob a tese de que o paciente dedica-se às atividades criminosas pelo fato de não exercer atividade lícita, pois estava desempregado à época dos fatos. Ademais, a quantidade da droga apreendida - 2,71g de cocaína -, apesar de nociva, não foi tão elevada a ponto de indicar, juntamente com as circunstâncias em que ocorreu o delito, a dedicação do acusado às atividades criminosas. - O STF, ao julgar o HC n. 111.840/ES, por maioria, declarou incidentalmente a inconstitucionalidade do § 1º do art. 2º da Lei 8.072/1990, com a redação dada pela Lei n. 11.464/2007, afastando, dessa forma, a obrigatoriedade do regime inicial fechado para os condenados por crimes hediondos e equiparados. - Hipótese em que o paciente é primário, condenado à pena não superior a 4 anos de reclusão, com análise favorável das circunstâncias judiciais, razão pela qual faz jus ao regime inicial aberto, conforme art. 33, § 2º, alínea c, do CP. - Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício, para restabelecer a sentença que fixou as penas em 2 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão e 221 dias-multa e modificar o regime inicial de cumprimento da pena para o aberto. (HC 336.143/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 09/08/2016, DJe 16/08/2016). E sendo assim, analisando os autos, tendo sido a reprimenda final estabelecida em patamar inferior a 4 anos de reclusão, fixo o regime inicial aberto para o cumprimento da pena.

Cumpra-se destacar que, apesar da Resolução nº 5 editada pelo Senado Federal, que suspendeu a expressão "vedada a conversão em penas restritivas de direitos" presente no parágrafo 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/06, não seria o caso de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito ou da suspensão condicional da pena - nos termos dos artigos 44 e 77, ambos do Código Penal - pois não se mostram medidas suficientes e adequadas ao presente caso. Ante o exposto, julgo PROCEDENTE a ação penal que a Justiça Pública move contra Marcos Pereira para CONDENÁ-LO à pena privativa de liberdade de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, no regime inicial aberto, e ao pagamento de 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa, no valor unitário mínimo legal, por violação ao disposto no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06.

O acusado poderá apelar em liberdade. Considerando que foi fixado regime inicial aberto, entendo que a prisão do réu não mais se justifica.

Expeça-se alvará de soltura.

Nos termos da Lei nº 11.343/06, após o trânsito em julgado, oficie-se à autoridade policial com a determinação de destruição da porção reservada, para eventual contraprova, das drogas apreendidas.

Após o trânsito em julgado, decreto o perdimento e determino a destruição das 2 (duas) sacolas plásticas preta e verde apreendidas, bem como da mochila preta - conforme auto de exibição e apreensão de fls. 11/12 - tendo em vista que as provas produzidas nos autos demonstraram tratar-se de instrumentos do tráfico ilícito de entorpecentes. Oficie-se à autoridade policial competente.

No que tange às custas processuais, diante da nomeação de Defensor Público Estadual, tem-se que foi deferida tacitamente a assistência judiciária gratuita ao réu. E sendo assim, fica suspenso o pagamento das custas, nos termos do disposto no artigo 12 da Lei nº 1.060/1950.

P.I.C.

Guaruja, 10 de abril de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA